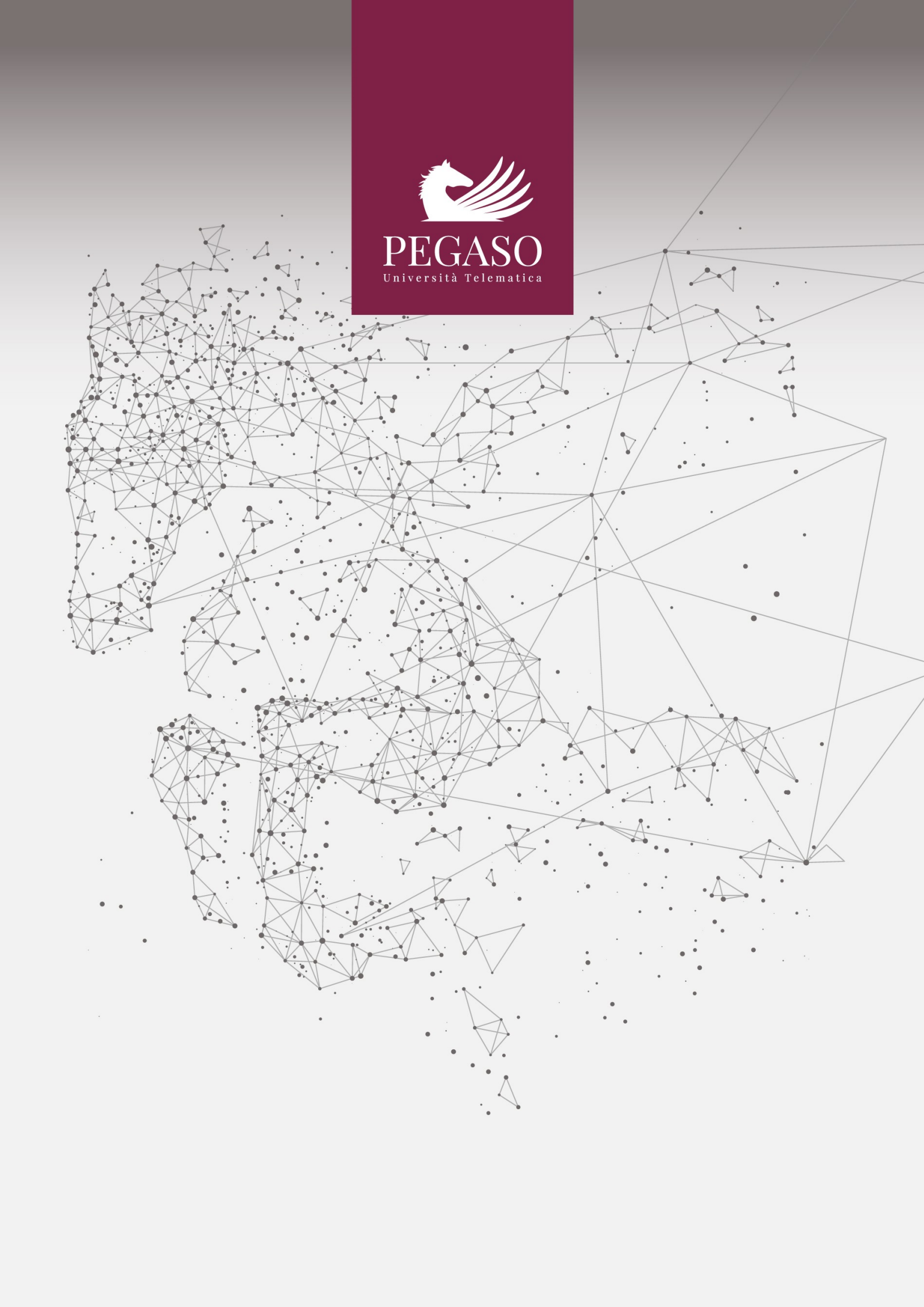

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROFILI COSTITUZIONALI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 3
2. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL DIRITTO EURO-UNITARIO 9
3. REGOLAMENTI E DIRETTIVE 11
4. IL CASO PROMUSICAE 13
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Profili costituzionali della proprietà intellettuale

La Costituzione è la fonte primaria del diritto italiano, il che significa che ogni altra regola del nostro sistema in contrasto con essa è destinata a venire meno, secondo i meccanismi studiati dal diritto pubblico (declaratoria di incostituzionalità da parte delle Corte Costituzionale per le norme di livello primario come quelle contenute in una legge del Parlamento o in un decreto legislativo delegato ovvero disapplicazione nel caso concreto ad opera del giudice per quelle di livello inferiore).

Per tale motivo occorre anzitutto esaminare il quadro costituzionale in cui si colloca la tutela della proprietà intellettuale.

Partendo dal diritto d'autore, sebbene il primo non sia espressamente riconosciuto dalla Costituzione, una tutela si rinviene in varie disposizioni della Carta.

Ciò ha particolare rilievo rispetto sia all'interpretazione delle norme in materia di diritto d'autore sia alla loro "resistenza" a censure di costituzionalità (come emerge, ad esempio, da Corte Cost. 108/1995)[1].

In specie, si rinviene la tutela autoriale nei seguenti articoli:

- Art. 2 Diritti inviolabili dell'uomo: ad esso si riconduce la tutela della personalità dell'autore, estrinsecata nell'opera dell'ingegno, nonché quella dei diritti morali;
- Art. 3 Rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana: vanno considerati anche gli interessi del fruitore delle opere dell'ingegno, il che può avvenire mediante diverse forme di protezione delle stesse (produzione statale, sussidio ai privati, riconoscimento di diritti esclusivi);

[1] Secondo la Corte Costituzionale "è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui, a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, precludono in modo assoluto all'acquirente la facoltà di dare in noleggio il compact disc contenente la detta opera musicale, in riferimento agli art. 3, 9, 41 e 42 cost.". Dunque, viene respinta la tesi secondo cui sono incostituzionali le norme della LDA nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di *compact disc* la facoltà di darli a noleggio. In specie, non si ritengono dette norme in contrasto con i principî della libera iniziativa economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9), per converso riconoscendo "dignità" e rilievo costituzionale al diritto d'autore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Art. 9 Promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca: trovano fondamento costituzionale anche le utilizzazioni libere, i limiti alla durata del diritto e, più in generale, la tutela dell'interesse della collettività alla diffusione delle opere dell'ingegno;
- Art. 21 Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero: esso ha un legame diretto con le utilizzazioni libere di cui agli artt. 65 e 66 LDA, anche se esso va inteso come diritto costituzionalmente garantito di esprimere le proprie idee, non di utilizzare indiscriminatamente quello altrui (!);
- Art. 33 Libertà dell'arte e della scienza: il principio trova attuazione nelle utilizzazioni libere di cui agli artt. 68 e 70 LDA;
- Art. 35 Tutela del lavoro in tutte le sue forme: oltre che insieme all'art.4 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il diritto al lavoro e l'obbligo di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, va letto unitamente all'art. 6 LDA, posto che la creazione dell'opera è da intendersi anche quale particolare espressione del lavoro intellettuale; pure in relazione alla norma de qua si comprendono le regole sul titolo di acquisto, nonché quelle sull'equo compenso di cui agli artt. 18-bis, comma 5, 46-bis, 80, comma 2, lett. f), e 84 LDA (alla cui lettura si rinvia);
- Art. 42 Tutela del diritto di proprietà: la riconduzione a tale disposizione del diritto d'autore, ne assicura una maggiore protezione, oltre che la funzionalizzazione all'economia di mercato, pure secondo la lettura proposta dall'analisi economica del diritto.

Venendo al diritto industriale, un primo riferimento è costituito dall'art. 41 della Costituzione, il quale tutela l'impresa nella prospettiva soggettiva della libertà di iniziativa economica di chi la esercita (con una espressione molto ampia, che si presta e si è prestata ad interpretazioni diversissime).

Qui interessa soprattutto sottolineare come il moderno diritto industriale rifletta fondamentalmente i nuovi assetti costituzionali, che contemperano quella libertà con altra libertà fondamentale, cioè quella di espressione (in relazione alla libera diffusione delle informazioni), che - come si è visto - rileva anche per il diritto d'autore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il principale fattore di complicazione nell'analisi della materia è rappresentato dalla comunanza di rango costituzionale dei diritti dei titolari delle privative e di quelli che l'ordinamento assegna ai terzi in ordine all'accesso alle informazioni.

Quanto ai primi (i diritti di privativa industriale) è innegabile il loro rango costituzionale così come il conflitto con i diritti di accesso dei terzi.

In proposito, gioca un ruolo rilevantissimo nella risoluzione del conflitto il principio di proporzionalità e bilanciamento, che rimanda ad una duplice esigenza:

a) ogni intervento limitativo di diritti individuali di rango costituzionale deve fondarsi su ragioni di interesse generale;
b) ove ciò si verifichi legislatori e giudici devono comporre gli interessi in conflitto in modo da non sacrificare la funzione essenziale del diritto subordinato.

Ad esempio, l'interesse collettivo al libero uso delle informazioni alla base delle innovazioni si deve coordinare con quello alla tutela dell'investimento necessario alla loro creazione, il che avviene ponendo dei limiti all'esercizio e alla durata del diritto.

In effetti, va riconosciuto – come visto – il rango costituzionale della attività volta all'investimento in ricerca e sviluppo, anche ai sensi dell'art. 9 Cost. con riferimento in generale al progresso scientifico ed ai sensi dell'art. 42 Cost. con riferimento alla proprietà (pur con tutte le differenze fra quella fisica e quella intellettuale): ma la sua protezione potrebbe avvenire, in astratto, anche solo con un meccanismo di finanziamento pubblico oppure di dominio pubblico pagante (in cui per l'utilizzatore lo sfruttamento è libero, previo pagamento di un compenso predeterminato).

Il sistema delle privative industriali appare per vari motivi preferibile ed è più in armonia con i meccanismi del mercato e della libertà contrattuale, senza che – tuttavia – esso si possa sottrarre al confronto (in base a quanto detto) con le teorie economiche dell'innovazione, rispetto alle quali si possono richiamare:

- l'idea dell'innovazione come "shock esogeno", idoneo a introdurre nella realtà una nuova risorsa produttiva di cui l'impresa può appropriarsi (così come di qualsiasi altra risorsa

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

esterna), con conseguente suo diritto a fare integralmente propri i risultati del suo investimento, soprattutto ove frutto di strategie imprenditoriali, autonomamente decise da ciascuna impresa;

- la teoria sistemica in cui le innovazioni appaiono come un flusso alimentato non solo dalle strategie proprie della singola impresa, ma soprattutto dall'esistenza di un ambiente competitivo generale, in cui i "giocatori" sono sia le imprese già affermate, sia gli innovatori indipendenti.

In un quadro di questo tipo, in cui si contrappongono le due visioni appena sintetizzate, le ragioni della protezione della proprietà industriale come necessario premio/incentivo all'innovazione sono contestate da coloro che ritengono il processo innovativo in grado di auto-alimentarsi spontaneamente, per cui il "diritto di prima vendita" (cioè il diritto a collocare per primi sul mercato il singolo trovato) sarebbe già un vantaggio competitivo sufficiente alla creazione intellettuale.

Queste tesi (almeno quelle estreme) sono poi alimentate da un preconcetto analogo a quello sorto rispetto al diritto d'autore.

Si afferma, infatti, che la proprietà industriale introduce un monopolio temporaneo e un diritto "anticoncorrenziale": per cui essa dovrebbe essere ammessa solo nella misura in cui attribuisca un vantaggio competitivo collocato nell'ambito di un processo dinamico, in cui il titolare del diritto di esclusiva non è affatto monopolista in senso economico, ma competitore in un mercato aperto.

In tale prospettiva la proprietà industriale non solo non è un "male inevitabile", ma diventa una necessaria regola del gioco, volta a fornire una chance rafforzata (oltre al diritto di prima vendita) per far sì che il processo innovativo non rallenti: venendo in esponente una continuità sistematica fra la disciplina della concorrenza e quella de qua.

Del resto, e tornando all'idea della funzione di "premio/incentivo" dell'esclusiva, si deve riconoscere che essa non è sempre necessaria per stimolare la creatività intellettuale degli individui: in certi campi di creazione artistica e per ragioni diverse nella ricerca scientifica di base,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la citata domanda pubblica può essere un incentivo insostituibile e più efficiente dello stesso mercato concorrenziale.

Ciò, piuttosto, può valere per la creatività individuale negli ambiti letterari ed artistici tradizionali (alcune grandi opere della letteratura, delle arti figurative e della musica sono state create in tempi che non conoscevano il diritto d'autore).

Non può valere, invece e certamente, nel campo della ricerca industriale, ove la creazione intellettuale è priva di possibilità di valorizzazione senza un investimento che sviluppi il progetto tecnico fino a farlo divenire un prodotto commerciabile.

Il problema è allora quello di determinare il giusto livello di protezione, in termini di durata e di ampiezza, come sopra si anticipava.

Tenendo conto delle riflessioni più complesse sui problemi della proprietà industriale, la funzione storica di "premio/incentivo" non viene allora meno in una situazione in cui l'innovazione è divenuta soprattutto innovazione progettata e realizzata all'interno di imprese. La funzione del premio semplicemente cambia: dalla creatività individuale (che rimane comunque la "materia prima" del processo innovativo) si passa all'investimento imprenditoriale (che però, a sua volta, significa anche capacità dell'impresa di stabilire strategie e progetti).

Se così è, la tutela costituzionale dell'impresa e la tutela costituzionale della concorrenza (da intendere come "concorrenza fra imprese") giustificano e impongono il riconoscimento di una tutela proprietaria delle creazioni che si formano all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, come parte integrante della proprietà dell'impresa.

Inoltre, il collegamento sistematico fra tutela dell'impresa e tutela della proprietà intellettuale è ancora più lineare se si considera la materia dei segni distintivi.

Per quanto ovvio, può essere opportuno ricordare che le creazioni intellettuali, nell'ambito dell'impresa, si rivolgono idealmente in due direzioni diverse.

Alcune tendono a produrre comunicazione verso i consumatori; altre tendono a tradursi in nuovi prodotti e in migliori offerte commerciali, con riferimento alle innovazioni produttive e,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ancora, organizzative, finanziarie e commerciali (non sempre protette da diritti tipici di proprietà industriale).

Tali assunti portano l'esigenza di allargamento dei diritti di proprietà industriale: la tutela del marchio come strumento di comunicazione, la tutela delle creazioni intellettuali frutto di investimenti rilevanti, l'allargamento della tutela brevettuale, la tutela diretta delle informazioni aziendali riservate e del know-how in senso proprio, la tutela dei diritti sportivi come risultato di attività imprenditoriale, e via dicendo.

In una parola, i diritti di proprietà intellettuale non sono da ricollegare a norme eccezionali, dettate dal legislatore in contrasto con supposti principi di libertà (di espressione, di concorrenza e quant'altro): secondo una idea ha forse un senso rispetto a un mondo ideale formato di soli individui indipendenti, non in un mondo caratterizzato dalla concorrenza fra imprese, che si relazionano pianificando e attuando strategie produttive e commerciali, al fine di ottenere il consenso dei consumatori.

Una seconda linea di sviluppo è quella della necessaria imputazione soggettiva dei diritti di proprietà industriale in capo all'impresa in sé: secondo una conclusione che, di nuovo, non è il risultato dell'applicazione di supposte norme eccezionali, le quali sottrarrebbero agli individui il frutto del proprio lavoro, per attribuirli ad una entità esterna ed astratta.

Al contrario, se una invenzione è frutto di un progetto di ricerca e investimento formato all'interno di un'organizzazione imprenditoriale, l'attribuzione dei diritti che ne derivano all'impresa stessa costituisce una necessità vitale, per l'efficienza del sistema (altrimenti mancherebbe l'incentivo principale a produrre innovazione) e deve ritenersi una coerente esplicazione della tutela costituzionale dell'impresa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La proprietà intellettuale nel diritto euro-unitario

In questo quadro generale si colloca anche il diritto dell'Unione Europea sulla IP.

In un primo momento le comunità europee hanno avuto a disposizione e hanno applicato soltanto due discipline "esterne" rilevanti per la proprietà intellettuale, cioè le regole relative al diritto antitrust e quelle sulla libera circolazione, senza che la IP trovasse una solida base nelle istituzioni europee.

A partire dalla entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2009), l'UE ha assunto una competenza esplicita anche in materia di diritti di proprietà intellettuale (in specie con gli articoli 114 e 118) e gli stessi – sebbene regolamentati dalle legislazioni nazionali – sono dunque disciplinati anche dalla UE.

L'articolo 118 del TFUE stabilisce infatti che nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello della stessa Unione.

L'attività legislativa dell'Unione in questo settore mira principalmente ad armonizzare taluni aspetti specifici dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la creazione di un sistema europeo unico, come nel caso del Marchio dell'Unione Europea e del Disegno o Modello Europeo e, ancora, come avverrà presto per i brevetti, con il Brevetto Europeo ad Effetto Unitario (ed il Tribunale Unificato dei Brevetti).

Uno dei principi cardine dell'attività di armonizzazione della proprietà intellettuale in Europa è il principio dell'esaurimento.

Tale regola generale prevista dal diritto dell'Unione Europea nell'ambito dei diritti di proprietà industriale comporta che il titolare di tali diritti, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell'Unione Europea, perde le relative facoltà di privativa e, quindi, che egli non possa

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

opporsi "all'importazione di un prodotto immesso in libera pratica in un altro Stato membro". Siffatta teoria è applicabile a tutti i settori della proprietà industriale.

Tale principio si occupa di mediare tra due interessi tutelati nella Unione Europea e, in genere, contrapposti:

1) l'esclusività dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
2) la libera circolazione dei beni e dei servizi.

La teoria dell'esaurimento dei diritti non vale in presenza della commercializzazione di un prodotto contraffatto né nei confronti di prodotti immessi all'esterno dello Spazio Economico Europeo (secondo l'art. 6 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - TRIPs).

Così e ad esempio, nel 1999 la Corte di Giustizia si è pronunciata nella sentenza Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois et Fils SA/GB-Unic SA, affermando che neppure gli Stati Membri sono autorizzati a stabilire nel proprio diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio a prodotti posti "in libera pratica" in un paese terzo[2] .

[2] Il caso riguardava l'importazione in Belgio, senza il consenso del titolare del marchio, di scarpe legittimamente fabbricate nel Salvador da un licenziatario della società statunitense Sebago – che con altri distributori operava anche nella Comunità Europea – e acquistate da una società belga che le aveva poi messe in vendita nei supermercati. Nel richiamare il precedente "*Silhouette*", la Corte stabilisce che l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solamente se i prodotti sono stati messi in commercio nella Comunità (nel SEE, dopo l'entrata in vigore del relativo accordo) e che le direttive in materia di marchi non attribuiscono agli Stati membri la possibilità di stabilire nel proprio ordinamento nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti messi in commercio in paesi terzi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Regolamenti e direttive

Vi sono molti regolamenti e direttive che cercano di armonizzare taluni aspetti specifici dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la creazione di un sistema europeo unico, in parallelo ai sistemi nazionali, come per il marchio europeo, i disegni europei e il brevetto europeo ad effetto unitario.

Premesso che vi sono molti regolamenti e direttive rilevanti, occorre comprendere in sintesi come tali fonti incidano sull'ordinamento italiano.

Il regolamento è una fonte che ha portata generale, cioè equivale ad una legge del Parlamento (si dirige a persone e situazioni non previamente determinati, nel senso che è generale e astratto) ed è immediatamente obbligatorio in tutti i suoi elementi euro-unitari e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Si tratta di un atto giuridico vincolante e diretto non solo agli Stati Membri, ma anche ai singoli, nel senso che esso produce effetti nei confronti di tutti coloro - autorità pubbliche e privati - soggetti al rispetto del diritto dell'Unione Europea.

Pertanto, uno Stato Membro non può unilateralmente adottare provvedimenti volti a limitare l'applicazione del regolamento, né può farne un'applicazione incompleta o selettiva: se vi sono leggi dello Stato italiano in contrasto con esso, ciascun giudice le può disapplicare dando prevalenza al regolamento, il quale – ancora – non ha bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati Membri nel loro ordinamento interno.

Proprio l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi è il carattere che distingue il regolamento dalla direttiva, che è obbligatoria solo nel fine che intende perseguire: essa obbliga gli stati membri a un determinato risultato, per cui il singolo legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo e si dice comunemente che la direttiva comporta il solo ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Peraltro, la direttiva deve essere sempre recepita – cioè trasfusa in una fonte del diritto nazionale, per quanto qui interessa italiano – che consenta all'Italia di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva stessa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dunque, i destinatari di essa sono solo gli stati e i singoli, in principio, non possono basare diritti sulla medesima.

Tuttavia, la Corte di Giustizia ha stabilito che in determinate circostanze le direttive non attuate e per le quali il termine sia scaduto, pur non essendo direttamente applicabili possono avere effetti diretti.

Esso possono essere idonee a creare diritti in capo ai singoli, che li possono invocare di fronte ai giudici nazionali: in specie se – oltre ad essere sufficientemente dettagliate e a prevedere diritti specifici e non condizionati – sono relative ai rapporti fra il cittadino e lo Stato.

In altre parole, l'idoneità a produrre effetti diretti di una direttiva inattuata è solo "verticale", cioè se i diritti previsti possono essere fatti valere nei confronti degli organi statali, altrimenti resterà al cittadino – quando mancano i suddetti requisiti oppure gli effetti sono solo "orizzontali", cioè relativi a rapporti fra privati – la possibilità di una azione di danni contro lo Stato italiano.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il caso Promusicae

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 Gennaio 2008, i giudici comunitari si sono pronunciati circa il rapporto – nell'ordinamento comunitario e in quelli nazionali - tra la normativa posta a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la legislazione sulla protezione dei dati personali.

Tale decisione è stata accolta con reazioni contrastanti, stante le sempre più frequenti contese che in tutta Europa (e non solo) vedono le major e i provider di servizi di comunicazione elettronica contrastarsi nelle aule di giustizia sul delicato terreno della tutela dei dati personali degli utenti a fronte della richiesta di identificazione mediante la raccolta e comunicazione dei loro indirizzi IP dalle reti di file-sharing.

Nel caso di specie una delle parti era la Productores de Música de España ("Promusicae"), cioè un'associazione spagnola senza scopo di lucro dei produttori ed editori soprattutto di registrazioni musicali ma anche audiovisive.

Essa aveva richiesto al giudice nazionale che un provider spagnolo di accessi Internet, la Telefonica de España SAU ("Telefonica") le comunicasse l'identità e il domicilio di determinati utenti di rete.

La Promusicae aveva infatti identificato tali soggetti in base ai cosiddetti indirizzi IP, nonché in base alla data e all'ora di connessione, affermando di aver individuato una serie di utenti (di cui appunto chiedeva l'identificazione a Telefonica) che in determinati periodi si scambiavano file musicali e fonogrammi in violazione dei diritti d'autore e di utilizzazione economica di titolarità dei suoi soci.

Ciò, in specie, attraverso il programma – denominato "KaZaA" - di condivisione di archivi (cosiddetto "peer to peer" o "file-sharing") che consentiva l'accesso nelle cartelle condivise dei computer personali connessi in rete.

Per agire in giudizio (in sede civile) contro i corrispondenti utenti, Promusicae chiedeva che il fornitore di accesso interessato, cioè Telefonica, le comunicasse a quali utenti fossero attribuiti,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

nei periodi da essa indicati, gli indirizzi IP identificati: essendo Telefonica tecnicamente in grado di rintracciare la connessione di volta in volta utilizzata, grazie alle informazioni conservate anche dopo l'interruzione della connessione circa quando e a quale utente essa ha attribuito un determinato indirizzo IP.

Il giudice adito emetteva inizialmente un'ordinanza con cui intima a Telefonica di trasmettere le informazioni richieste, ma essa presentava opposizione, in quanto, ai sensi dell'art. 12 della Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico, essa sosteneva di non poter fornire al giudice le informazioni richieste.

Difatti, ai sensi del citato art. 12 della legge spagnola sul commercio elettronico (di implementazione della relativa direttiva comunitaria sul commercio elettronico"), il fornitore si un servizio di comunicazione elettronica (o provider) può comunicare i dati che è tenuto a conservare per legge solo nel contesto di un'indagine penale o quando ciò sia necessario per la tutela della pubblica sicurezza o della sicurezza nazionale.

Il giudice spagnolo, sebbene ritenesse plausibile tale interpretazione, non reputava la disposizione compatibile con il diritto comunitario, sottoponendo dunque alla Corte di Giustizia delle Comunità europee una specifica questione pregiudiziale: se il diritto comunitario consentisse agli Stati membri di circoscrivere all'ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale - ad esclusione, quindi, dei processi civili - il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni ed il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione, che incombe sugli operatori della rete e di servizi di comunicazione elettronica, sui fornitori di accesso alle reti di telecomunicazione e sui fornitori di servizi di conservazione dei dati.

Nella sentenza che chiude la controversia tra Promusicae e Telefonica la Corte afferma che il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, l'obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Diverse direttive comunitarie - affermano i giudici UE - sono dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell'ambito della società dell'informazione, l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d'autore.

Tuttavia, questa tutela non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, senza contare che le direttive sulla tutela dei dati personali offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all'obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico.

La Corte rileva poi che tra le deroghe consentite dalle direttive sulla tutela dei dati personali figurano le misure necessarie per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

E poiché la direttiva 2002/58/CEE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non specifica i diritti e le libertà oggetto di tale deroga, essa dev'essere interpretata - continuano i giudici - nel senso che esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà né le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile.

Quindi essa non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di istituire l'obbligo di divulgare dati personali nell'ambito di un procedimento civile, ma nemmeno impone loro di prevedere tale obbligo.

Quanto alle direttive in materia di proprietà intellettuale, la Corte constata che neppure esse richiedono che gli Stati membri istituiscano l'obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile.

Ciò considerato, la Corte sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione solleva la questione della necessaria conciliazione degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall'altra, i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo.

A tale proposito, la Corte conclude che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento comunitario.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità

In questa lunga partita tra major e provider la Corte assegna un importante punto in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sostenendo che - almeno nei procedimenti civili - essi non sono tenuti a privilegiare i diritti di proprietà intellettuale di terzi a discapito della privacy dei loro utenti, in quanto non vi è nessun obbligo normativo (né sul piano delle direttive comunitarie a tutela dell'IP né sul quello della legislazione comunitaria sulla tutela dei dati personali) di fornire i relativi dati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- R. CASO, Nota a Corte Cost. 6 aprile 1995, n. 108, in Foro it., 1995, I, 1724;
- R. ROMBOLI Nota a Corte Cost. 6 aprile 1995, n. 108, in Foro it., 1995, I, 1724;
- P. MARCHETTI e L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi sul diritto della concorrenza, Cedam, 2016.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).